

Sachverhalt: Förderung KommunalWärme Lindenhafen GmbH

Aktenzeichen

Wirtschaftsförderung Stadt Lindenhafen – AZ: WF-2023-0047/EUR

A. Beteiligte

Rolle	Name / Bezeichnung	Einzelheiten
Zuwendungsgeber	Stadt Lindenhafen (Niedersachsen)	Mittelgroße Gemeinde, ca. 42.000 Einwohner, Landkreis Heidegrund
Zuwendungsempfänger	KommunalWärme Lindenhafen GmbH (KWL)	100 % kommunales Unternehmen; Fernwärmeversorgung
Beschwerdeführer	HeatBridge AG	Privates Wärmecontracting-Unternehmen, Sitz in Hannover
Zuständige Behörde (national)	Niedersächsisches Wirtschaftsministerium	Fachaufsicht Wirtschaftsförderung / Beihilfestelle Land
Europäische Kommission	Generaldirektion Wettbewerb (DG COMP)	Beihilfekontrolle nach Art. 108 AEUV
Verwaltungsgericht	VG Lüneburg	3. Kammer, zuständig für öffentliches Wirtschaftsrecht

B. Ausgangslage

Die Stadt Lindenhafen liegt im Landkreis Heidegrund in Niedersachsen und versorgt seit Jahrzehnten weite Teile ihrer Innenstadt sowie zwei Gewerbegebiete über ein erdgasbetriebenes Fernwärmenetz. Betreiberin dieses Netzes ist die KommunalWärme Lindenhafen GmbH (nachfolgend: KWL), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt. Die KWL beschäftigt 78 Mitarbeiter; ihr Jahresumsatz lag im Geschäftsjahr 2022 bei rund 19,2 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der europäischen Klimaschutzziele und der nationalen Vorgaben zur Wärmewende hat der Stadtrat Lindenhafen am 14. März 2023 mit 29 zu 8 Stimmen beschlossen, der KWL einen kommunalen Investitionszuschuss in Höhe von 14 Mio. Euro zu gewähren. Mit diesen Mitteln soll die KWL bis Ende 2026 das bestehende Gasnetz schrittweise auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umstellen: Konkret ist die Errichtung einer zentralen Wärmepumpenanlage (Leistung: 12 MW thermisch), die Erneuerung von ca. 8,4 km Leitungstrassen sowie der Anschluss von derzeit noch nicht versorgten Stadtgebieten (Neubaugebiete Am Sandkrug und Westliches Industriegelände) geplant.

C. Wirtschaftlicher und rechtlicher Hintergrund des Zuschusses

Der Investitionszuschuss wird auf der Grundlage der kommunalen Wirtschaftsförderungsrichtlinie der Stadt Lindenhafen (WFR-Lindenhafen 2021) sowie der Niedersächsischen Richtlinie zur Förderung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen vom 12. Mai 2021 (Nds. MBl. 2021, S. 724) gewährt. Die zuständige Kämmererei der Stadt prüfte das Vorhaben nach kommunalhaushaltsrechtlichen Maßstäben (§§ 110 ff. NKomVG) und stellte im März 2023 fest, dass die Stadtfinanzen eine vollständige Eigenkapitalfinanzierung nicht zulassen.

Die Stadtverwaltung – vertreten durch Wirtschaftsförderin Dr. Anja Rennekamp – vertrat zunächst die Auffassung, der Zuschuss unterfalle nicht dem europäischen Beihilferecht. Zur Begründung wurde ausgeführt, die KWL übe eine Aufgabe der Daseinsvorsorge im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV aus; zudem handle es sich um eine rein lokale Förderung ohne grenzüberschreitende Wirkung. Ein förmliches Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission nach Art. 108 Abs. 3 AEUV wurde nicht eingeleitet.

Im weiteren Verlauf der internen Prüfung wies die Rechtsabteilung der Stadt (Leiter: RA Markus Glöckner) darauf hin, dass der Zuschuss möglicherweise als staatliche Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV zu qualifizieren sei, da die KWL als wirtschaftliches Unternehmen auf einem Markt tätig sei, auf dem auch private Wettbewerber agieren. Die Rechtsabteilung empfahl, die Anwendbarkeit der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) – insbesondere der Umweltschutz-Beihilfen nach Art. 36 AGVO – sowie der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 zu prüfen, bevor der Bescheid erlassen werde.

D. Erteilung des Förderbescheids

Trotz noch offener Rechtsfragen erließ die Wirtschaftsförderungsabteilung der Stadt am 5. September 2023 den Förderbescheid (AZ: WF-2023-0047/EUR). Der Bescheid setzt den Zuschuss auf 14 Mio. Euro fest, verteilt auf drei Tranchen (je nach Baufortschritt), und enthält u. a. folgende Nebenbestimmungen:

- Auflage zur vorrangigen Vergabe von Tiefbauleistungen an Unternehmen mit Betriebssitz im Landkreis Heidegrund;
- Berichtspflicht gegenüber der Stadt über CO₂-Einsparungen jährlich zum 31. März;
- Rückforderungsvorbehalt bei Zweckentfremdung der Mittel.

Als Rechtsgrundlage wurde neben der Niedersächsischen Klimaschutzrichtlinie auch Art. 106 Abs. 2 AEUV (Daseinsvorsorge-Ausnahme) angeführt; eine Notifizierung nach Art. 108 Abs. 3 AEUV oder eine Freistellung nach der AGVO wurde nicht formal dokumentiert.

E. Reaktion der HeatBridge AG

Die HeatBridge AG, ein privates Wärmecontracting-Unternehmen mit Sitz in Hannover und einem Niederlassungsbüro in der Nachbarkommune Heidestadt, betreibt in der Region mehrere dezentrale Wärmeversorgungsanlagen und hatte der Stadt Lindenhafen im Jahr 2022 ein konkurrierendes Angebot für den Aufbau des klimaneutralen Wärmenetzes unterbreitet. Dieses Angebot war im Stadtrat ohne förmliche Begründung abgelehnt worden.

Nachdem der Förderbescheid im Amtsblatt der Stadt Lindenhafen vom 12. September 2023 veröffentlicht wurde, beauftragte die HeatBridge AG die Rechtsanwaltskanzlei Stern & Heuer (Hannover) mit der Prüfung rechtlicher Schritte. Die Kanzlei identifizierte drei Angriffspunkte:

1. **EU-beihilferechtlicher Verstoß:** Der Bescheid gewähre eine nicht notifizierte staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb verfälsche und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtige (Art. 107 Abs. 1 AEUV). Eine Freistellung nach Art. 107 Abs. 3 AEUV oder der AGVO sei nicht dokumentiert.

2. **Verstoß gegen die Vergabeklausel:** Die Nebenbestimmung zur bevorzugten Vergabe an regionale Unternehmen verstoße gegen die unionsrechtlichen Vergabegrundsätze und ggf. gegen die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) sowie die Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV).
3. **Gleichheitsverstoß:** Das private Konkurrenzangebot sei ohne sachlichen Grund übergangen worden; dies stelle eine ungerechtfertigte staatliche Diskriminierung dar.

Am 3. Oktober 2023 reichte die HeatBridge AG eine förmliche Beschwerde bei der Europäischen Kommission (DG COMP) ein und beantragte gleichzeitig beim Verwaltungsgericht Lüneburg einstweiligen Rechtsschutz gegen den Vollzug des Förderbescheids.

F. Verfahrensstand

Das Verwaltungsgericht Lüneburg (Az.: 3 A 228/23) hat am 18. Oktober 2023 die aufschiebende Wirkung der Klage der HeatBridge AG angeordnet und die Stadt Lindenhafen aufgefordert, bis zum 15. Dezember 2023 zur beihilferechtlichen Einordnung des Zuschusses Stellung zu nehmen. Die Vorsitzende Richterin der 3. Kammer, Dr. Friederike Lenz, hat in der mündlichen Verhandlung über den Eilantrag signalisiert, dass das Gericht erwäge, dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine Vorlagefrage nach Art. 267 AEUV zu stellen, sollte die Auslegung des Tatbestandsmerkmals der "Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten" im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV klärungsbedürftig bleiben.

Parallel hat die Europäische Kommission mit Schreiben vom 28. November 2023 (Ref.: SA.2023/0847) die Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/1589 aufgefordert, innerhalb von 20 Arbeitstagen Auskunft über den Fördervorgang zu erteilen. Die Bundesregierung hat die Anfrage an das Land Niedersachsen weitergeleitet, welches seinerseits die Stadt Lindenhafen um eine detaillierte Stellungnahme gebeten hat.

G. Offene Rechtsfragen

Die Akte wirft folgende zentrale Rechtsfragen auf:

- Liegt eine "staatliche Beihilfe" i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vor, insbesondere: Besteht eine grenzüberschreitende Handelsbeeinträchtigung auch bei einem rein lokalen Fernwärmenetz?
- Greift die DAWI-Ausnahme (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) des Art. 106 Abs. 2 AEUV, und falls ja: unter welchen Voraussetzungen?
- Ist der Zuschuss nach der AGVO (Art. 36: Umweltschutzbeihilfen für Energieeffizienz) freigestellt, und welche formellen Anforderungen (Anzeige, Transparenzdatenbank) wurden nicht erfüllt?
- Ist die Vergabeklausel (Bevorzugung regionaler Unternehmen) mit den Grundfreiheiten vereinbar?
- Kann das VG Lüneburg eine Vorlagefrage nach Art. 267 AEUV stellen, und welche Frage ist hinreichend präzise formulierbar?

H. Chronologie

Datum	Ereignis
2022 (März)	HeatBridge AG unterbreitet Alternativangebot an die Stadt Lindenhafen

14.03.2023	Stadtratsbeschluss zur Förderung der KWL (29:8 Stimmen)
05.09.2023	Erlass Förderbescheid AZ: WF-2023-0047/EUR
12.09.2023	Veröffentlichung im Amtsblatt Lindenhafen
03.10.2023	Beschwerde HeatBridge AG bei DG COMP; Eilantrag VG Lüneburg
18.10.2023	VG Lüneburg ordnet aufschiebende Wirkung an (Az.: 3 A 228/23)
28.11.2023	Auskunftsanfrage EU-Kommission (Ref.: SA.2023/0847)
15.12.2023	Frist für Stellungnahme der Stadt gegenüber VG Lüneburg

Stadt Lindenhafen

Der Buergemeister – Wirtschaftsfoerderungsabteilung –

Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen

Tel.: 05841/9200-0 | wirtschaftsfoerderung@lindenhafen.de

Lindenhafen, 5. September 2023

KommunalWaerme Lindenhafen GmbH

– Geschaeftsfuehrung –

Industriestrasse 12, 29482 Lindenhafen

**Betreff: Foerderbescheid – Investitionszuschuss WaermeWende
Lindenhafen 2026 – AZ: WF-2023-0047/EUR**

I. Tenor (Entscheidung)

1. Bewilligung

Der Stadt Lindenhafen bewilligt der KommunalWaerme Lindenhafen GmbH auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 2023/SR/017 vom 14. Maerz 2023 einen nicht rueckzahlbaren Investitionszuschuss in Hoehe von:

14.000.000,00 Euro (vierzehn Millionen Euro)

fuer das Vorhaben „WaermeWende Lindenhafen 2026“.

2. Zweck – Teilmassnahmen

Teilmassnahme	Betrag (€)
Errichtung Waermepumpenanlage (12 MW thermisch)	6.400.000
Erneuerung Leitungstrassen (8,4 km)	4.800.000
Netzanschluss Neubaugebiet Am Sandkrug	1.500.000
Netzanschluss Westliches Industriegelaende	1.100.000
Projektmanagement und	200.000

Planungsleistungen	
Summe	14.000.000

3. Auszahlung in drei Tranchen

- Tranche 1 (40 % = 5.600.000 €): nach Baubeginn und Vergabeabschluss, fruehestens 1. Januar 2024.
- Tranche 2 (40 % = 5.600.000 €): nach Fertigstellung der Waermepumpenanlage, spaetestens 31. Dezember 2025.
- Tranche 3 (20 % = 2.800.000 €): nach Vorlage des Verwendungsnachweises, spaetestens 30. Juni 2027.

II. Nebenbestimmungen

§ 1 - Zweckbindung Die Zuschussmittel sind ausschliesslich fuer die im Tenor genannten Teilmassnahmen zu verwenden. Jede Zweckaeenderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der bewilligenden Stelle.

§ 2 - Vergabe Die Zuwendungsempfaengerin hat bei der Vergabe die Vorschriften des Vergaberechts (GWB, VgV, VOB/A, UVgO) zu beachten. Die Sollvorschrift zur Beruecksichtigung regionaler Unternehmen bei Tiefbauleistungen begruendet keinen Rechtsanspruch.

§ 3 - Berichtspflicht Jaehrlich zum 31. Maerz (erstmals 31. Maerz 2025) ist ein Zwischenbericht mit CO₂-Einsparungen, Baufortschritt und Mittelverwendung vorzulegen.

§ 4 - Aufbewahrung Belege und Vergabeunterlagen sind mindestens zehn Jahre nach Bewilligung der letzten Tranche aufzubewahren.

§ 5 - Weiterleitungsverbot Weiterleitung von Zuschussmitteln an Dritte ist ohne Zustimmung der bewilligenden Stelle unzuulaessig.

§ 6 - Rueckforderungsvorbehalt Rueckforderung bei: zweckwidriger Verwendung; Nicht-Vorlage von Nachweisen nach Nachfristsetzung; Vaeusserung, Stilllegung oder Zweckentfremdung der Anlagen innerhalb von zehn Jahren. Zinssatz: 5 über Basiszinssatz (§ 247 BGB) ab Auszahlungstag.

III. Begrueendung

Die KommunalWaerme Lindenhafen GmbH betreibt das kommunale Fernwaermenetz der Stadt. Das Vorhaben dient dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit. Rechtsgrundlagen: §§ 110, 111 NKomVG; kommunale

Wirtschaftsfoerderungsrichtlinie 2021; Niedersaechsische Klimaschutzrichtlinie vom 12. Mai 2021 (Nds. MBl. 2021, S. 724); Stadtratsbeschluss Nr. 2023/SR/017.

Die Wirtschaftsfoerderungsabteilung geht davon aus, dass die Foerdermassnahme als kommunale Daseinsvorsorge-Infrastruktur (Art. 106 Abs. 2 AEUV) keiner Notifizierungspflicht nach Art. 108 Abs. 3 AEUV unterliegt. Eine Gruppenfreistellung nach Art. 36 AGVO wird geprueft. Alternative Finanzierungsinstrumente wurden erwaegen, aber als nicht hinreichend eingestuft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei: Stadt Lindenhafen, Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen. Nach Zurueckweisung des Widerspruchs kann Klage beim Verwaltungsgericht Lueneburg, Auf der Hude 2, 21339 Lueneburg erhoben werden. Dritte koennen bei Betroffenheit ebenfalls Klage erheben.

V. Anlagen

- Anlage 1 – Stadtratsbeschluss Nr. 2023/SR/017 vom 14.03.2023
- Anlage 2 – Projektbeschreibung WaermeWende Lindenhafen 2026 (KWL, August 2023)
- Anlage 3 – Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kaemmerei
- Anlage 4 – Niedersaechsische Klimaschutzrichtlinie vom 12.05.2021
- Anlage 5 – Vorabpruefvermerk der Rechtsabteilung (AGVO, De-minimis)

Thomas Brennecke

Buergermeister der Stadt Lindenhafen

Bearbeitung: Dr. Anja Rennekamp, Wirtschaftsfoerderung, Tel.: 05841/9200-42

Aktenvermerk: Richtlinienumsetzung und AGVO-Prüfung

Vermerk-Nr.: RV-2023-EUR-003

Stadt Lindenhafen

Rechtsabteilung

Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen

An: Wirtschaftsförderungsabteilung, z.Hd. Dr. Anja Rennekamp

Von: Markus Glöckner, Leiter Rechtsabteilung

Datum: 20. August 2023

Betreff: Vermerk zur EU-beihilferechtlichen Einordnung des Investitionszuschusses für die KommunalWärme Lindenhafen GmbH – AGVO-Prüfung, De-minimis, DAWI

A. Anlass und Prüfungsauftrag

Auf Anforderung der Wirtschaftsförderungsabteilung (Schreiben vom 3. August 2023, AZ: WF-2023-0047/EUR) prüft die Rechtsabteilung, ob der geplante Investitionszuschuss in Höhe von 14 Mio. Euro an die KommunalWärme Lindenhafen GmbH (KWL) einer EU-beihilferechtlichen Genehmigung bedarf oder ob eine Freistellung greift. Dieser Vermerk gibt den Stand der Prüfung zum 20. August 2023 wieder.

B. Tatbestandsprüfung: Art. 107 Abs. 1 AEUV

Staatliche Beihilfen sind nach Art. 107 Abs. 1 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie vier kumulativ zu erfüllende Merkmale aufweisen:

1. Staatliche Mittel / staatliche Zurechenbarkeit

Der Zuschuss stammt aus dem Haushalt der Stadt Lindenhafen (öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft). Er wird durch Beschluss eines demokratisch legitimierten Organs (Stadtrat) bewilligt. **Merkmal: erfüllt.**

2. Selektiver Vorteil

Die KWL erhält einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, den sie auf dem Kapitalmarkt zu vergleichbaren Konditionen nicht hätte erhalten können. Private Kapitalgeber hätten nach dem Market Economy Investor Test (MEIT) diese Konditionen nicht akzeptiert, da die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kämmerei eine Kapitalrendite von unter 2 % p.a. ausweist. **Merkmal: erfüllt.**

3. Wirtschaftliche Tätigkeit des Begünstigten

Die KWL ist als GmbH verfasst und erbringt gegen Entgelt die Fernwärmeversorgung für private Haushalte und Gewerbebetriebe. Der Umstand der 100-prozentigen kommunalen

Gesellschafterstruktur schließt die Qualifikation als "Unternehmen" i.S.d. Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht aus (EuGH, Urteil vom 12. September 2000, Rs. C-180/98 bis C-184/98, Pavlov). **Merkmal: erfüllt.**

4. Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten

Dies ist die rechtlich umstrittenste Frage. Die Kommission wendet nach ihrer Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe (ABl. 2016 C 262/1, Rn. 190 ff.) auch auf lokal tätige Unternehmen das Handelskriterium an, sofern der Markt potenziell für Wettbewerber aus anderen Mitgliedstaaten zugänglich ist. Das Fernwärmegeschäft ist grundsätzlich standortgebunden; jedoch können Wärmecontractingunternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten auf dem deutschen Markt tätig werden (Art. 49, 56 AEUV). **Merkmal: rechtlich zweifelhaft, aber nach Kommissionspraxis tendenziell erfüllt.**

Zwischenergebnis: Es bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass der Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt ist. Die Annahme, es handele sich lediglich um eine rein lokale Maßnahme ohne Handelsbeeinträchtigung, ist rechtlich riskant.

C. Prüfung: Ausnahme nach Art. 106 Abs. 2 AEUV (DAWI)

Voraussetzungen

Art. 106 Abs. 2 AEUV stellt Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) betraut sind, von den Beihilferegeln frei, soweit die Anwendung der Wettbewerbsregeln die Erfüllung der übertragenen Aufgaben rechtlich oder tatsächlich verhindern würde.

Prüfung der Voraussetzungen

Kriterium	Anforderung	Bewertung
Übertragungsakt	Förmliche Betrauung durch die Gemeinde	Nicht dokumentiert. Der Gesellschaftsvertrag der KWL enthält keine DAWI-Betrauungsklausel.
Definition der DAWI-Aufgabe	Klare Beschreibung von Umfang, Gebiet, Laufzeit	Fehlt. Kein förmlicher Betrauungsakt nach Altmark/DAWI-Rahmen 2012.
Altmark-Kriterien (EuGH C-280/00)	Notwendige Parameter, kosteneffizientestes Unternehmen	Nicht geprüft. Keine Parameterfestsetzung vor Betrauung.
Verhältnismäßigkeit	Kein Überausgleich	Fraglich. Vollfinanzierung durch Zuschuss ohne Abzug marktüblicher Rendite.

Ergebnis: Die DAWI-Ausnahme greift mangels förmlicher Betrauung und fehlender Altmark-Konformität derzeit **nicht**. Eine nachträgliche Betrauung wäre theoretisch möglich, ändert aber nichts an der Notifizierungspflicht für den geplanten Zuschuss, da die Konditionen nicht dem Altmark-Test genügen.

D. Prüfung: Freistellung nach AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014)

Einschlägige Tatbestände

Art. 36 AGVO – Beihilfen für Energieeffizienz außerhalb von Gebäuden

Diese Norm deckt Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz von Produktions- und Dienstleistungsanlagen außerhalb von Gebäuden ab. Für Wärmepumpenanlagen zur Fernwärmeversorgung kommt zusätzlich **Art. 41 AGVO** (Beihilfen für erneuerbare Energien und Speicher) in Betracht.

Prüfung der formellen Voraussetzungen (Art. 6, 7, 9 AGVO)

Anforderung	Status
Anmeldung / Transparenzpflicht (Art. 9 AGVO)	Ausstehend. Beihilfe muss in der Transparenzdatenbank der Kommission veröffentlicht werden.
Anreizeffekt (Art. 6 AGVO)	Zuschussantrag vor Baubeginn? – Stadtratsbeschluss vom 14.03.2023, geplanter Baubeginn: Q1 2024. Anreizeffekt wohl gegeben.
Schwellenprüfung (Art. 4 AGVO)	14 Mio. Euro. Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a AGVO gilt eine Anmeldeschwelle von 15 Mio. Euro für Umweltschutzbeihilfen. Schwellenwert unterschritten.
Berechnung der förderfähigen Kosten	Art. 36 Abs. 5 AGVO: förderfähig sind die Mehrkosten gegenüber einem vergleichbaren Referenzprojekt (Gasnetz-Modernisierung). Diese Berechnung liegt noch nicht vor.
Beihilfeintensität	Für mittlere Unternehmen: max. 45 % der förderfähigen Kosten; KWL ist Tochter der Stadt → nicht KMU i.S.d. Anhang I AGVO (verbundenes Unternehmen). Anwendbare Intensität: max. 30 % (Art. 36 Abs. 7 AGVO).

Berechnungsbeispiel Beihilfeintensität

Angenommen, die förderfähigen Mehrkosten (Wärmepumpe vs. Gaskessel als Referenzanlage) betragen 8 Mio. Euro:

- Zulässige Beihilfe (30 %): 2.400.000 Euro
- Beantragter Zuschuss: 14.000.000 Euro

Der geplante Zuschuss **überschreitet die zulässige Beihilfeintensität erheblich**, wenn nicht der gesamte Investitionsbetrag als förderfähige Mehrkosten qualifiziert werden kann.

Ergebnis AGVO: Eine Freistellung ist nicht von vornherein ausgeschlossen, erfordert aber (i) die Berechnung der förderfähigen Mehrkosten, (ii) die Prüfung der Beihilfeintensität und (iii) die nachträgliche Veröffentlichung in der Transparenzdatenbank. Das Vorhaben sollte zudem in der **nationalen Beihilferegister-Datenbank** der Bundesregierung angemeldet werden.

E. Prüfung: De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013

Der Zuschuss beläuft sich auf 14 Mio. Euro. Die De-minimis-Grenze liegt bei **200.000 Euro** über drei Steuerjahre. Eine Freistellung nach der De-minimis-VO scheidet daher aus.

F. Handlungsempfehlungen

1. **Keine sofortige Bescheiderteilung** ohne vollständige Klärung der Beihilfefrage. Das Risiko einer rechtswidrigen Beihilfe mit anschließender Rückforderungspflicht ist erheblich.

2. **Berechnung förderfähiger Mehrkosten** i.S.d. Art. 36 Abs. 5 AGVO durch externen Gutachter (Vergleich Wärmepumpe vs. Referenz-Gasanlage).
3. **Förmlicher Betrauungsakt** für die KWL beschließen, wenn die DAWI-Route weiterverfolgt werden soll (vor Bescheiderteilung).
4. **Anmeldung in der EU-Transparenzdatenbank** (falls AGVO-Freistellung angestrebt), spätestens within 12 Monate nach Bewilligung (Art. 9 Abs. 1 AGVO).
5. **Notifizierung nach Art. 108 Abs. 3 AEUV** erwägen, falls keine Freistellungsgrundlage greift – Stand-still-Pflicht beachten.

Lindenhafen, 20. August 2023

Markus Glöckner

Leiter Rechtsabteilung, Stadt Lindenhafen

Verteiler: Dr. Anja Rennekamp (WiF), Bürgermeister Brennecke (z.K.), Akten WF-2023-0047/EUR

Beschwerde an die Europäische Kommission – DG COMP

Beschwerde-Referenz (intern): HB-2023-EU-004

HeatBridge AG

Hannoversche Straße 88

30161 Hannover

Telefon: 0511 / 8842-0

Vertreten durch:

Rechtsanwälte Stern & Heuer Partnerschaft mbB

Georgsplatz 14

30159 Hannover

(RAin Miriam Heuer, LL.M. Europarecht)

An die

Europäische Kommission

Generaldirektion Wettbewerb (DG COMP)

Beihilfenkontrolle / Staatliche Beihilfen

Rue Joseph II 70

B-1000 Brüssel

Betreff: Beschwerde gemäß Art. 24 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2015/1589 wegen mutmaßlich rechtswidriger und mit dem Binnenmarkt unvereinbarer staatlicher Beihilfe der Stadt Lindenhafen (Deutschland) an die KommunalWärme Lindenhafen GmbH – Ref.: SA.2023/0847

Datum: 3. Oktober 2023

I. Beschwerdeführerin und ihr Interesse

Die HeatBridge AG ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit Sitz in Hannover, das im Bereich der dezentralen und leitungsgebundenen Wärmeversorgung in Deutschland und weiteren EU-Mitgliedstaaten tätig ist (Wärmelieferung, Contracting, Planung und Betrieb von Heizkraftwerken und Wärmepumpenanlagen). Die Gesellschaft beschäftigt rund 310 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von ca. 48 Mio. Euro.

Die HeatBridge AG betreibt eine Niederlassung in Heidestadt (Landkreis Heidegrund, Niedersachsen) und war im März 2022 als Bieterin im Rahmen einer informellen Markterkundung der Stadt Lindenhafen für den Aufbau eines klimaneutralen Fernwärmenetzes tätig. Ihr Angebot wurde von der Stadt ohne förmliche Begründung abgelehnt; stattdessen entschied die Stadt, die Maßnahme an die eigene Tochtergesellschaft KommunalWärme Lindenhafen GmbH (KWL) zu vergeben und diese mit einem kommunalen Zuschuss von 14 Mio. Euro auszustatten.

Die Beschwerdeführerin ist unmittelbar und spezifisch von der streitgegenständlichen Beihilfemaßnahme betroffen: Sie verliert den Auftrag, den sie ohne die selektive Förderung der Mitbewerberin hätte erhalten können, und wird strukturell aus dem Markt der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in der Region verdrängt.

II. Beschreibung der angegriffenen Maßnahme

1. Maßnahme

Mit Bescheid vom 5. September 2023 (AZ: WF-2023-0047/EUR) gewährt die Stadt Lindenhafen (Niedersachsen, Deutschland) ihrer vollständig im Kommunalbesitz stehenden Tochtergesellschaft, der KommunalWärme Lindenhafen GmbH, einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss in Höhe von **14.000.000 Euro** für den Umbau des Fernwärmenetzes auf klimaneutrale Versorgung (Projekt "WärmeWende Lindenhafen 2026").

2. Begünstigte

KommunalWärme Lindenhafen GmbH, Industriestraße 12, 29482 Lindenhafen; 100 % Tochtergesellschaft der Stadt Lindenhafen; tätig in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung.

3. Kein Notifizierungsverfahren

Nach Kenntnis der Beschwerdeführerin wurde vor Erlass des Förderbescheids kein Notifizierungsverfahren nach Art. 108 Abs. 3 AEUV bei der Kommission eingeleitet. Die Maßnahme ist daher als rechtswidrige Beihilfe zu behandeln (Stand-still-Verstoß).

III. Rechtliche Begründung

1. Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV

a) Staatliche Mittel und Zurechenbarkeit

Der Zuschuss stammt aus dem Haushalt der Stadt Lindenhafen, einer deutschen Gebietskörperschaft. Die Entscheidung wurde durch den Stadtrat als demokratisch legitimates Organ getroffen. Das Merkmal der staatlichen Zurechenbarkeit ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 16. Mai 2002, Rs. C-482/99, Stardust Marine) erfüllt, wenn die öffentliche Hand an der Entscheidung beteiligt ist. Daran besteht kein Zweifel.

b) Selektiver Vorteil

Die KWL erhält einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, den ein verständiger privater Investor zu vergleichbaren Konditionen nicht gewährt hätte. Die eigene Wirtschaftlichkeitsberechnung der Stadt weist eine Kapitalrendite von unter 2 % p.a. aus; dies liegt weit unterhalb marktüblicher Renditeanforderungen. Der Market Economy Investor Test (MEIT) ist damit nicht erfüllt. Die

Selektivität der Maßnahme ergibt sich daraus, dass ausschließlich die kommunale Tochtergesellschaft – und nicht der Markt allgemein – begünstigt wird.

c) Wirtschaftliche Tätigkeit

Die KWL ist als GmbH privatrechtlich organisiert und erbringt ihre Wärmeleistungen gegen marktübliche Entgelte. Der Umstand, dass es sich um ein öffentliches Unternehmen handelt, ist nach der Rechtsprechung des EuGH unerheblich (Pavlov; Höfner und Elser, Rs. C-41/90). Die KWL ist "Unternehmen" i.S.d. AEUV.

d) Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten

Nach der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe (ABl. 2016 C 262/1, Rn. 190 ff.) liegt eine Handelsbeeinträchtigung vor, wenn der Begünstigte auf einem Markt tätig ist, auf dem Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten aktiv sind oder aktiv werden könnten. Der Wärmecontracting-Markt ist für EU-ausländische Unternehmen offen; mehrere skandinavische und niederländische Wärmeversorgungsunternehmen sind auf dem deutschen Markt tätig. Die Beschwerdeführerin selbst erwägt, ihren Geschäftsbetrieb mit Partnern aus Schweden und den Niederlanden auszubauen. Die Beeinträchtigung des Handels ist damit zu bejahen.

Die pauschale Annahme der Stadt, es handle sich um eine rein lokale Maßnahme ohne Handelsbezug, ist rechtlich nicht tragfähig. Nach dem Urteil des EuGH vom 14. Oktober 1987 (Rs. 278/84, Deutschland/Kommission) ist keine spürbare Beeinträchtigung erforderlich.

2. Keine anwendbare Freistellung

a) Art. 106 Abs. 2 AEUV (DAWI)

Ein förmlicher Betrauungsakt für die KWL liegt nicht vor. Die Altmark-Kriterien (EuGH, Rs. C-280/00) sind nicht erfüllt, da keine vorherige Parameterfestsetzung zur Ausgleichsberechnung erfolgt ist und nicht dargelegt wurde, dass die KWL als das kostengünstigste Unternehmen ausgewählt wurde. Die DAWI-Ausnahme greift daher nicht.

b) AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014)

Aus den öffentlich zugänglichen Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass eine AGVO-Freistellung ordnungsgemäß dokumentiert wurde. Insbesondere fehlt die Berechnung der förderfähigen Mehrkosten (Art. 36 Abs. 5 AGVO) und die Veröffentlichung in der EU-Transparenzdatenbank (Art. 9 AGVO). Die Beihilfeintensität (14 Mio. Euro bei voraussichtlichen Mehrkosten von deutlich unter 14 Mio. Euro) überschreitet die zulässige Grenze von 30 % erheblich.

c) De-minimis

Der Zuschuss übersteigt die De-minimis-Grenze (200.000 Euro) um das Siebzigfache. Eine Freistellung scheidet aus.

3. Vergaberechtliche Bedenken

Die Nebenbestimmung des Förderbescheids, wonach bei Tiefbauleistungen "vorrangig" Unternehmen mit Betriebssitz im Landkreis Heidegrund berücksichtigt werden sollen, verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Vergaberechts und begrenzt die Möglichkeit der Beschwerdeführerin sowie anderer EU-ausländischer Unternehmen, an den subventionierten Aufträgen teilzunehmen. Dies verletzt Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit).

IV. Marktstörung und Wettbewerbsbeeinträchtigung

Die Förderung der KWL in Höhe von 14 Mio. Euro versetzt diese in die Lage, das Fernwärmenetz zu Konditionen anzubieten, die ohne staatliche Subvention nicht erzielbar wären. Für die Beschwerdeführerin bedeutet dies:

- **Preisunterbietung:** Die KWL kann Fernwärme zu Preisen unterhalb der Vollkosten anbieten, da ein Großteil der Investitionskosten durch staatliche Mittel gedeckt ist.
- **Marktzugangssperre:** Die selektive Förderung macht es privaten Wettbewerbern strukturell unmöglich, mit einem subventionierten kommunalen Unternehmen zu konkurrieren, ohne eigene Verluste zu erleiden.
- **Langfristige Marktverzerrung:** Da das Fernwärmenetz eine natürliche Monopol Tendenz aufweist und Leitungsnetze auf Jahrzehnte errichtet werden, sichert die staatliche Förderung der KWL eine dauerhafte Monopolstellung in Lindenhafen.
- **Abschreckungswirkung:** Andere kommunale Körperschaften werden durch das Beispiel Lindenhafen ermutigt, ähnliche Zuschüsse ohne Notifizierung zu gewähren, was zu einer systematischen Marktverzerrung im deutschen Fernwärmemarkt führen würde.

V. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt die Kommission,

1. die streitgegenständliche Beihilfemaßnahme der Stadt Lindenhafen als mit dem Binnenmarkt unvereinbare, nicht notifizierte staatliche Beihilfe i.S.d. Art. 107 Abs. 1 AEUV zu qualifizieren;
2. die Bundesrepublik Deutschland im Wege einer Auskunftsanordnung nach Art. 10 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2015/1589 zur vollständigen Übermittlung der Förderunterlagen aufzufordern;
3. ein förmliches Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten;
4. einstweilige Maßnahmen nach Art. 13 der Verordnung (EU) 2015/1589 zur Aussetzung der weiteren Auszahlung des Zuschusses anzuordnen, sofern der Vollzug von der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht bereits ausgesetzt wurde;
5. die Bundesrepublik Deutschland zur Rückforderung der rechtswidrig gewährten Beihilfe zuzüglich Zinsen (Art. 16 der Verordnung (EU) 2015/1589) zu verpflichten, sollte sich die Unvereinbarkeit der Maßnahme mit dem Binnenmarkt bestätigen.

VI. Anlagen

6. Anlage A – Förderbescheid der Stadt Lindenhafen, AZ: WF-2023-0047/EUR, vom 05.09.2023 (Kopie aus dem Amtsblatt Lindenhafen vom 12.09.2023)
7. Anlage B – Angebot der HeatBridge AG an die Stadt Lindenhafen vom März 2022
8. Anlage C – Ablehnungsschreiben der Stadt Lindenhafen vom April 2022 (ohne Begründung)
9. Anlage D – Auszug Gesellschaftsvertrag KWL (öffentliche Register-Version)
10. Anlage E – Gutachterliche Stellungnahme Stern & Heuer zur beihilferechtlichen Einordnung, September 2023
11. Anlage F – Bevollmächtigungsnachweis

Hannover, 3. Oktober 2023

Miriam Heuer, Rechtsanwältin

Stern & Heuer Partnerschaft mbB

(bevollmächtigt durch die HeatBridge AG)

VERWALTUNGSGERICHT LUENEBURG

3. Kammer

VORLAGEBESCHLUSS

gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV

Az.: 3 A 228/23

Klaegerin:	HeatBridge AG, Hannoversche Str. 88, 30161 Hannover Prozessbevollmaechtigte: RA Stern & Heuer Partnerschaft mbB, Hannover
gegen	
Beklagte:	Stadt Lindenhafen, Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen, vertr. d. Buergermeister
Beigeladene:	KommunalWaerme Lindenhafen GmbH, Industriestr. 12, 29482 Lindenhafen
wegen:	Aufhebung eines Foerderbescheids / staatliche Beihilfen

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Lüneburg durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Friederike Lenz sowie die Richterinnen am Verwaltungsgericht Sabine Hartmann und Katrin Voss am 18. Januar 2024 beschlossen:

I. Aussetzung und Vorlage

Das Verfahren wird gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV ausgesetzt. Dem Gerichtshof der Europaeischen Union werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

II. Vorlagefragen

Vorlagefrage 1 – Handelskriterium (Art. 107 Abs. 1 AEUV)

Ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahin auszulegen, dass eine kommunale Subvention, die eine Gebietskörperschaft einer zu 100 Prozent in ihrem Eigentum stehenden Gesellschaft fuer den Umbau eines lokal betriebenen Fernwaermenetzes auf erneuerbare Energiequellen gewaehrt, geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeintaechtigen, wenn (a) das Fernwaermenetz ausschliesslich innerhalb des Gemeindegebiets betrieben wird und keine physische Leitungsverbindung zu einem anderen Mitgliedstaat besteht, (b) Waermecontractingunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten grundsaeztlich in der Lage waeren, auf demselben lokalen Markt Waermedienstleistungen anzubieten, wenn keine staatliche Foerderung der kommunalen Gesellschaft existierte, und (c) der Subventionsbetrag (14 Millionen Euro) den Schwellenwert der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 deutlich uebersteigt?

Vorlagefrage 2 – DAWI-Ausnahme (Art. 106 Abs. 2 AEUV)

Ist Art. 106 Abs. 2 AEUV dahin auszulegen, dass eine kommunale Waermeversorgungsgesellschaft, die auf Grundlage eines Gesellschaftsvertrags und eines kommunalpolitischen Stadtratsbeschlusses, nicht aber aufgrund eines gesonderten foermlichen Betrauungsakts, die Fernwaermeversorgung eines Gemeindegebiets uebernimmt, als mit einer DAWI betraut angesehen werden kann? Sofern bejaht: Welche Mindestanforderungen stellt das Unionsrecht an einen solchen Betrauungsakt, und ist ein nachtraeglicher Betrauungsakt heilend wirksam?

Vorlagefrage 3 – AGVO / Art. 36 VO (EU) Nr. 651/2014

Ist Art. 36 AGVO dahin auszulegen, dass (a) der Referenzfall fuer die Berechnung der beihilfefaeihigen Mehrkosten bei einem bisher gasbeheizten Fernwaermenetz die hypothetischen Kosten einer modernisierten Gasanlage sind, und (b) eine kommunale Gesellschaft, die zu 100 Prozent im Eigentum der zuwendungsgebenden Koerperschaft steht, als Grossunternehmen mit einer zulaessigen Beihilfeintensitaet von maximal 30 % der beihilfefaeihigen Mehrkosten einzustufen ist?

Vorlagefrage 4 – Grundfreiheiten / Vergabeklausel (Art. 49, 56 AEUV)

Sind Art. 49 und Art. 56 AEUV dahin auszulegen, dass eine Nebenbestimmung in einem kommunalen Foerderbescheid, die den

Zuwendungsempfänger anhaelt, Auftraege fuer Tiefbauleistungen vorrangig an Unternehmen mit Betriebssitz im oertlichen Landkreis zu vergeben, auch dann mit den Grundfreiheiten unvereinbar ist, wenn diese Nebenbestimmung als blosse Sollvorschrift ohne Rechtsanspruch der beguendigten Unternehmen ausgestaltet ist?

III. Sachverhalt und Entscheidungserheblichkeit

Die Beklagte, die Stadt Lindenhafen (Niedersachsen), hat ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft, der KommunalWaerme Lindenhafen GmbH (KWL), mit Bescheid vom 5. September 2023 (AZ: WF-2023-0047/EUR) einen nicht rueckzahlbaren Investitionszuschuss in Hoehe von 14.000.000 Euro fuer den Umbau des kommunalen Fernwaermenetzes auf erneuerbare Energien gewaehrt. Als Rechtsgrundlage wurde u. a. Art. 106 Abs. 2 AEUV angefuehrt. Ein Notifizierungsverfahren nach Art. 108 Abs. 3 AEUV wurde nicht eingeleitet.

Die Klaegerin, HeatBridge AG, ist ein privates Waermecontractingunternehmen, das der Stadt 2022 ein konkurrierendes Angebot unterbreitet hatte. Das Angebot wurde ohne sachliche Begrueendung abgelehnt. Die Klaegerin beantragt die Aufhebung des Foerderbescheids. Mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 hat die Kammer die aufschiebende Wirkung der Klage angeordnet.

Die Kammer sieht sich mit unionsrechtlichen Auslegungsfragen konfrontiert, die entscheidungserheblich sind und zu denen keine hinreichend klare Aussage in der Rechtsprechung des EuGH vorliegt (acte clair ist nicht gegeben). Das Verfahren wird daher ausgesetzt.

IV. Kosten

Die Kostenentscheidung bleibt der Abschlussentscheidung nach Eingang der Vorabentscheidung des Gerichtshofs vorbehalten.

Lüneburg, 18. Januar 2024

Dr. Friederike Lenz
Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht

Sabine Hartmann
Richterin am Verwaltungsgericht

Katrin Voss
Richterin am Verwaltungsgericht

Beglaubigte Abschrift / Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle: M. Schroeder

Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Lüneburg

Az.: 3 A 228/23

VERWALTUNGSGERICHT LÜNEBURG

3. Kammer

VORLAGEBESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

HeatBridge AG,

Hannoversche Straße 88, 30161 Hannover,

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Stern & Heuer Partnerschaft mbB,

Georgsplatz 14, 30159 Hannover

gegen

Stadt Lindenhafen,

vertreten durch den Bürgermeister,

Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen,

– Beklagte –

Beigeladene:

KommunalWärme Lindenhafen GmbH,

Industriestraße 12, 29482 Lindenhafen

wegen: Aufhebung eines Förderbescheids / Unterlassung der Auszahlung staatlicher Beihilfen

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Lüneburg durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Friederike Lenz sowie die Richterinnen am Verwaltungsgericht Sabine Hartmann und Katrin Voss

am **18. Januar 2024**

beschlossen:

I. Aussetzung des Verfahrens und Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union

Das Verfahren wird gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV ausgesetzt.

Dem **Gerichtshof der Europäischen Union** werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

II. Vorlagefragen

Vorlagefrage 1 (Handelskriterium / Art. 107 Abs. 1 AEUV)

Ist Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine kommunale Subvention, die eine Gebietskörperschaft einer zu 100 Prozent in ihrem Eigentum stehenden Gesellschaft für den Umbau eines lokal betriebenen Fernwärmenetzes auf erneuerbare Energiequellen gewährt, geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, wenn

a) das Fernwärmenetz ausschließlich innerhalb des Gemeindegebiets betrieben wird und keine physische Leitungsverbindung zu einem anderen Mitgliedstaat besteht,

b) Wärmecontractingunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten grundsätzlich in der Lage wären, auf demselben lokalen Markt Wärmedienstleistungen anzubieten, wenn keine staatliche Förderung der kommunalen Gesellschaft existierte,

c) der Subventionsbetrag (14 Millionen Euro) den Schwellenwert der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 deutlich übersteigt?

Vorlagefrage 2 (DAWI-Ausnahme / Art. 106 Abs. 2 AEUV)

Ist Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine kommunale Wärmeversorgungsgesellschaft, die auf der Grundlage eines Gesellschaftsvertrags und eines kommunalpolitischen Stadtratsbeschlusses, nicht aber aufgrund eines gesonderten förmlichen Betrauungsakts, die Fernwärmeversorgung eines Gemeindegebiets übernimmt, als mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut angesehen werden kann, sodass staatliche Zuschüsse für Investitionen in dieser Gesellschaft von den Beihilferegeln des AEUV ausgenommen sind?

Sofern die Frage bejaht wird: Welche Mindestanforderungen stellt das Unionsrecht an einen solchen Betrauungsakt, und ist es mit dem Unionsrecht vereinbar, dass der Betrauungsakt erst nach der Bewilligung der Subvention erlassen wird?

Vorlagefrage 3 (Anreizeffekt und AGVO / Verordnung (EU) Nr. 651/2014)

Ist Art. 36 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) dahin auszulegen, dass

a) der bei Berechnung der beihilfefähigen Kosten gemäß Art. 36 Abs. 5 AGVO maßgebliche Referenzfall für ein Fernwärmenetz, das bisher mit Erdgas betrieben wurde, die hypothetischen Kosten einer modernisierten Gasheizanlage oder einer anderen alternativen, konventionellen Wärmelösung sind,

b) eine kommunale Gesellschaft, die zu 100 Prozent im Eigentum der zuwendungsgebenden Gebietskörperschaft steht und daher als mit dieser verbundenes Unternehmen im Sinne von Anhang I Art. 3 Abs. 3 AGVO zu qualifizieren ist, als Großunternehmen einzustufen ist mit der Folge, dass die zulässige Beihilfeintensität nach Art. 36 Abs. 7 AGVO maximal 30 Prozent der beihilfefähigen Mehrkosten beträgt?

Vorlagefrage 4 (Grundfreiheiten und Vergabeklausel)

Sind Art. 49 und Art. 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass eine Nebenbestimmung in einem kommunalen Förderbescheid, die den Zuwendungsempfänger anhält, Aufträge für Tiefbauleistungen "vorrangig" an Unternehmen mit Betriebssitz im örtlichen Landkreis zu vergeben, auch dann mit den Grundfreiheiten unvereinbar ist, wenn diese Nebenbestimmung als bloße Sollvorschrift ohne Rechtsanspruch der begünstigten Unternehmen ausgestaltet ist?

III. Sachverhalt und Verfahrensstand

1. Tatsächlicher Hintergrund

Die Beklagte, die Stadt Lindenhafen (Niedersachsen), hat ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft, der KommunalWärme Lindenhafen GmbH (KWL), mit Bescheid vom 5. September 2023 (AZ: WF-2023-0047/EUR) einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss in Höhe von 14.000.000 Euro für den Umbau des kommunalen Fernwärmenetzes auf erneuerbare Energien gewährt. Als Rechtsgrundlage wurde u. a. Art. 106 Abs. 2 AEUV (Daseinsvorsorge-Ausnahme) angeführt.

Die Klägerin, HeatBridge AG, ist ein privates Wärmecontractingunternehmen, das der Stadt Lindenhafen im März 2022 ein konkurrierendes Angebot für denselben Netzbetrieb unterbreitet hatte. Das Angebot wurde ohne sachliche Begründung abgelehnt. Mit Klageerhebung am 3. Oktober 2023 beantragt die Klägerin die Aufhebung des Förderbescheids und hilfsweise die Feststellung seiner Rechtswidrigkeit.

Auf Antrag der Klägerin hat die Kammer mit Beschluss vom 18. Oktober 2023 die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Vollzug des Förderbescheids angeordnet. Die Beklagte hat daraufhin die Auszahlung der ersten Tranche vorläufig zurückgestellt.

2. Nationales Recht

Nach deutschem Recht hat ein Dritter, der durch den Vollzug einer rechtswidrigen Beihilfe in seinen eigenen Rechten verletzt wird, nach § 42 Abs. 2 VwGO eine subjektiv-öffentliche Klagebefugnis. Das Beihilfeverbot des Art. 108 Abs. 3 S. 3 AEUV entfaltet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der deutschen Verwaltungsgerichte eine drittschützende Wirkung, auf die sich die Klägerin berufen kann.

3. Unionsrechtliche Zweifelsfragen

Die Kammer sieht sich bei der Entscheidung des Rechtsstreits mit folgenden unionsrechtlichen Auslegungsfragen konfrontiert, die nach ihrer Auffassung entscheidungserheblich sind und zu denen keine hinreichend klare Aussage in der Rechtsprechung des Gerichtshofs vorliegt (*acte clair* ist nicht gegeben):

- Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Handelskriterium lässt offen, ab welchem Konkretisierungsgrad potenzieller grenzüberschreitender Wettbewerb ausreicht, um auch bei rein lokaler Infrastruktur eine Handelsbeeinträchtigung zu bejahen (vgl. EuGH, Urteil vom 14. Oktober 1987, Rs. 278/84; Kommissionsbekanntmachung ABl. 2016 C 262/1).
- Die Anforderungen an einen DAWI-Betrüungsakt wurden durch den DAWI-Rahmen 2012 (Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011, ABl. 2012 L 7/3) und die Altmark-Rechtsprechung (EuGH, Rs. C-280/00) präzisiert, lassen jedoch offen, ob ein nachträglicher Betrauungsakt heilend wirken kann.
- Bei Art. 36 AGVO fehlt eine gerichtliche Leitentscheidung zur Referenzfall-Methodologie für hybride Infrastrukturprojekte (Gas-zu-Erneuerbar-Umrüstung).

IV. Entscheidungserheblichkeit

Die Vorlagefragen sind entscheidungserheblich: Je nach Antwort des Gerichtshofs ist die Klage entweder begründet (Bescheid rechtswidrig wegen Verstoß gegen Art. 108 Abs. 3 AEUV) oder unbegründet (Maßnahme greift nicht in den Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV ein oder ist wirksam freigestellt). Die Kammer kann ohne die Vorabentscheidung keine abschließende Entscheidung treffen.

V. Kosten

Die Kostenentscheidung bleibt der Abschlussentscheidung nach Eingang der Vorabentscheidung des Gerichtshofs vorbehalten.

Lüneburg, 18. Januar 2024

Dr. Friederike Lenz

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht

Sabine Hartmann

Richterin am Verwaltungsgericht

Katrin Voss

Richterin am Verwaltungsgericht

Beglaubigte Abschrift

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle: M. Schröder